

1502316-18.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... com a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida. De fato, não há provas seguras de que o réu já praticava a traficância anteriormente. Ressalto que a existência de anotações anteriores, relativas a atos infracionais, não tem o condão de afastar o redutor. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATOS

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502316-18.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502316-18.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2316481/2021 - 3º Distrito Policial de Diadema, 4098/2021 - 3º Distrito Policial de Diadema, 2316481 - 03º D.P. DIADEMA, 4098/21/127 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO BARRETO DE BRITO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos,

PABLO BARRETO DE BRITO, qualificado à fl. 25, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, "caput", do Código Penal, porque, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 22h10, na Avenida Fundibem, altura do n.º 935, Casa Grande, nesta cidade e Comarca de Diadema, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, trazia consigo, para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros, 59 porções de "crack", com peso de 35,21g, 40 porções de cocaína, pesando 45,12g, e 52 porções de maconha, com peso de 239,2g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu passou por audiência de custódia às fls. 36/39 e 42, ocasião em que sua

prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

O réu foi notificado (fl. 66) e apresentou defesa prévia às fls. 69/70.

A denúncia foi recebida em 03/02/2022 (fls. 71/72).

O réu foi citado (fl. 113).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ato que se realizou de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas policiais e foi o réu interrogado, prosseguindo-se com os debates orais entre a acusação e a defesa.

Em alegações finais, a D. Promotora de Justiça requereu procedência do pedido, condenando-se o réu nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da confissão espontânea, sem reflexos na pena; não aplicação do tráfico privilegiado, em razão da dedicação habitual à prática criminosa; fixação do regime fechado; impossibilidade de recorrer em liberdade; não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; decretação do perdimento do dinheiro apreendido.

A D. Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu, com fundamento na fragilidade do conjunto probatório. Em caso de condenação, postulou a aplicação da pena-base no mínimo legal; aplicação da figura privilegiada no patamar máximo de redução da reprimenda; fixação do regime inicial aberto; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; possibilidade de recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitativa restou sobejamente comprovada pelo teor do boletim de ocorrência (fls. 14/17), do auto de exibição e apreensão (fl. 22), do laudo de constatação (fls. 27/29), do laudo pericial de objeto (fls. 120/122), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 114/116) e da prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em juízo, o réu confessou integralmente os fatos, nos termos da denúncia. Disse estar arrependido.

A confissão do réu, ademais, foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado a este juízo, a testemunha Marciano dos Santos Gomes, policial militar, afirmou que fez diligência na região, que é conhecido ponto de tráfico de drogas. Afirmou que foi feito um cerco no local, e adentrou no condomínio, visualizando dois indivíduos, os quais correram a perceberem a presença policial. Disse que um deles conseguiu se evadir, e seguiu no encalço do réu. Viu o momento em que ele dispensou uma pochete. Continuou a perseguir o acusado, conseguindo detê-lo. Retornou e pegou a pochete, no interior da qual estavam as drogas. Com o acusado havia certa quantia em dinheiro. O réu admitiu a traficância para o depoente. Disse que já tinha abordado o acusado antes, em uma biqueira, mas na ocasião ele fora identificado como sendo usuário.

No mesmo sentido, o depoimento do policial Luís Roytman de Campos, prestado em solo policial.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira "lei do silêncio", temendo sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o

réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocentes. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito.

Assim, a credibilidade do testemunho dos policiais não pode ser afastada.

Dessa forma, a significativa quantidade de droga apreendida em poder do réu (59 porções de "crack", com peso de 35,21g., 40 porções de cocaína, pesando 45,12g., e 52 porções de maconha, com peso de 239,2g.) e as circunstâncias em que se deu sua prisão (policiais estavam em patrulhamento de rotina, quando foram avisados de que dois indivíduos estariam praticando o tráfico no local dos fatos. Rumaram para o lugar indicado e fizeram o cerco a duas pessoas, tendo uma delas conseguido correr e fugir. O réu, por sua vez, também tentou correr e, enquanto isso, dispensou um estojo no chão; porém, foi alcançado e no estojo que foi recuperado os policiais encontraram os entorpecentes acima indicados, bem como a quantia de R\$ 401,50, em dinheiro, com o réu), evidenciam que, efetivamente, a droga encontrada pertencia a ele e se destinava à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cabe ressaltar que a condição de viciado do réu não ficou comprovada nos autos e que a mera alegação de que é usuário não é suficiente para excluir a prática do crime, pois é sabido que usuários de drogas acabam se envolvendo com o tráfico com a finalidade de sustentar o próprio vício. Frise-se, ainda, que a quantidade de droga encontrada em poder do réu é suficiente para afastar a possibilidade de que se tratasse de substância para consumo pessoal.

Assim, não restou configurada nenhuma causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, havendo provas suficientes para que seja condenado o réu nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes. Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Consigno que, apesar do pedido Ministerial de aumento da pena nesta etapa, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes, observo que o número de porções apreendidas individualmente com cada réu não é expressivo o suficiente para destoar da média das apreensões que costumeiramente ocorrem nesta Comarca.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes a considerar. Por outro lado, presente as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa (réu nascido em 21/04/2002 - fl. 25), porém, sem reflexo na dosimetria, tendo em vista que a pena já se encontra no piso legal e, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser conduzida a quem deste patamar, neste momento do cálculo.

Na terceira fase da dosimetria, deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/06. De acordo com entendimento amplamente majoritário do E. Supremo Tribunal Federal, "a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa" (HC n.º 124.107/SP, Primeira Turma, Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/11/14; HC n.º 122.626/SP, Primeira Turma, rel. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14; RHC n.º 118.008/SP, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/13; HC n.º 108.388/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/4/13; Recurso Ordinário em HC n.º 116.049, rel. Dias Toffoli; HC n.º 111.309/DF, rel. Ministro Roberto Barroso).

No caso em tela, anoto que as circunstâncias não indicam que o acusado tenha envolvimento de forma reiterada ou profissional com a atividade criminosa, fazendo

do tráfico o seu meio de vida. De fato, não há provas seguras de que o réu já praticava a traficância anteriormente. Ressalto que a existência de anotações anteriores, relativas a atos infracionais, não tem o condão de afastar o redutor. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO AR. 33, § 4.º, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de

argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Na linha dos precedentes desta Colenda Turma, a menção a atos infracionais praticados pelo agente não consiste fundamentação idônea para afastar a minorante em exame. Esse entendimento está em consonância com sistema de proteção integral assegurado a crianças e adolescentes por nosso ordenamento jurídico. 4. A teor das Súmulas 718 e 719/STF, figura-se inadmissível a fixação do regime inicial fechado com base em considerações abstratas acerca da gravidade do delito imputado. 5. Agravo regimental desprovido" (HC 202.574 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (§ 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A NEGAR O REDUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA PARA SE REFAZER A DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prática anterior de atos infracionais pelo paciente não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º da Lei 11.343/2006. 4. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente elididos. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido" (HC 191.992 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).

Deste modo, cabível a redução, no patamar de 1/2, levando-se em conta para a fixação deste patamar a quantidade, variedade e a natureza das drogas apreendidas. Registro que a utilização deste critério apenas na terceira fase permite um melhor equacionamento da pena e sua correta individualização, sem implicar bis in idem. Neste sentido, aliás, tem sido o posicionamento da E. 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal: "A quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para justificar o patamar de redução da pena em razão da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º da Lei de Tóxicos. Precedentes" (STF, 1.ª T., HC n.º 110.487/RS, rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 14/02/2012); e ainda: "A causa especial de diminuição de pena de que trata o § 4.º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada em apenas 1/6 (um sexto), num intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), com fundamento na quantidade de entorpecente, que é critério preponderante fixado na lei, revelando a justeza da sanção no caso concreto. Precedentes: HC 98.900, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/11/2010 e HC 94.559, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 04/11/2010" (STF, 1.ª T., HC n.º 104.195, rel. Min. Luiz Fux, j. 26/04/2011).

Assim, fixo a pena em 02 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão, mais ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Considerando a quantidade de pena fixada (inferior a 04 anos), a confissão, menoridade e primariedade do agente, bem como o tempo da prisão preventiva, fixo o regime inicial aberto, por entender, diante destas circunstâncias, ser este regime suficiente para fins de reprovação e prevenção da conduta a ele imputada.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar PABLO BARRETO DE BRITO qualificado nos autos, à pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Fixo, desde logo, as seguintes condições para cumprimento da pena em regime aberto (art. 115, da Lei n.º 7.210/84):

- (a) permanecer em sua residência durante o repouso e nos dias de folga;
- (b) sair para apenas para tratamento médico, estudo ou trabalho, retornando ao término do expediente;
- (c) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial;
- (d) comparecimento periódico em Juízo (em prazo a ser fixado no Juízo da Execução Criminal), para informar e justificar as suas atividades.
- (e) Não frequentar determinados lugares, a saber: pontos de venda de drogas ("biqueiras"), locais e eventos em que sejam oferecidas ao público, de forma gratuita ou onerosa, bebidas alcoólicas para consumo imediato (bares, bailes, festas, "baladas" e congêneres).

Considerando os precedentes do E. Supremo Tribunal Federal em casos assemelhados, a Resolução n.º 05, do Senado Federal, bem como a presença das condições legais para tanto (art. 44, do Código Penal), substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma na modalidade prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso IV, do CP), e outra na modalidade prestação pecuniária (art. 43, inciso I, do CP), eis que a pena aplicada é superior a 01 (um) ano, na forma do artigo 44, § 2.º, do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outros, na forma do artigo 46 do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da Execução na forma do artigo 149 da LEP. As tarefas deverão ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, até que venha a totalizar a pena imposta, na forma do artigo 46, § 3.º, do Código Penal.

Já a prestação pecuniária, que fixo no mínimo legal de 01 (um) salário-mínimo, consiste no pagamento de dinheiro a entidade pública ou privada de destinação social, a ser identificada pelo Juízo das Execuções Criminais.

As penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, que substituem a pena privativa de liberdade, são aplicadas sem prejuízo da multa cominada cumulativamente, eis que a substituição em questão somente alcança a reprimenda corporal e não a pena de multa. Em caso de reconversão a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime aberto, consoante fundamentação acima. Considerando a quantidade de pena aplicada e o regime inicial de seu cumprimento, bem como a ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Proceda-se à destruição das drogas, na forma do art. 72, da Lei n.º 11.343/2006. Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado:

- a) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;
- b) oficie-se ao IIRGD;
- c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;

Quanto ao estojo (fl. 23), não tem valor comercial. Assim, autorizo a destruição. Com relação ao valor apreendido (R\$ 401,50 - fls. 23 e 51), tratando-se de produto do tráfico, decreto seu perdimento em favor da União. Proceda-se conforme as determinações do artigo 63 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado, deverá ser destruído o restante do entorpecente, que foi armazenado para contraprova.
Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA